

《【문제5.1】

<사례>

행정청 A는 甲에게 식품위생법 위반을 사유로 영업정지 2개월 처분을 내리며, 처분서에는 미성년자에게 주류를 제공하였다는 사유만을 기재하였다. 甲은 이에 불복하여 취소소송을 제기하였다. 소송 계속 중 행정청 A는 甲이 사실은 영업소의 면적을 변경하고도 신고하지 않았다는 사실을 추가로 발견하고, 소송에서 이 사유를 새로운 처분사유로 내세워 처분의 정당성을 주장하고자 한다. 한편, 甲은 행정청 A가 보관하고 있는 처분 당시의 조사 자료와 행정심판 단계에서의 기록이 자신에게 유리한 증거가 될 것으로 판단하고 이를 확인하고자 한다.

(물음1) 행정청 A가 소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 사유를 추가하거나 변경하는 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술하라.》

<문제5.1의 물음1> 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대한 판례의 입장

I. 문제의 제기

- 사안에서 행정청 A는 영업정지처분의 취소소송 계속 중 처분서에 기재되지 않았던 새로운 위반사실을 처분사유로 추가하여 처분의 적법성을 주장하고자 한다. 쟁점으로 <소송 계속 중 처분 당시 기재하지 않았던 처분사유의 추가·변경이 허용되는지>와 <그 허용범위 및 한계>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 처분사유의 추가·변경의 허용 여부와 한계에 대하여 대법원 판례의 입장을 중심으로 서술한다.

II. 처분사유의 추가·변경의 의의 및 인정 여부

1. 의의

- 처분사유의 추가·변경이란 행정청이 처분 당시에 적시한 사유 외에 소송 계속 중에 새로운 사유를 추가하거나 당초의 사유를 다른 사유로 변경하여 처분의 적법성을 주장하는 것을 말한다.

2. 인정 여부에 관한 판례의 입장

- 명문의 규정이 없음에도 불구하고 판례는 소송경제와 행정의 적법성 확보라는 측면에서 일정한 한계 내에 처분사유의 추가·변경을 허용하고 있다. 다만 무제한적으로 허용할 경우 원고의 방어권을 침해할 수 있으므로 엄격한 요건을 요구한다.

III. 처분사유 추가·변경의 요건과 한계

1. 시간적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 처분 당시 이미 존재하고 있었던 사유여야 한다. 처분 이후에 발생한 새로운 사실이나 법령의 변경을 근거로 당초 처분의 적법성을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 즉, 처분 시를 기준으로 사유의 존부를 판단해야 한다.

2. 객관적 한계 : 기본적 사실관계의 동일성

(1) 동일성 판단 기준

- 대법원은 당초의 처분사유와 추가·변경하려는 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 경우에만 처분사유의 추가·변경을 허용한다. 여기서 동일성이란 처분사유를 법률적으로 평가하기 이전의 구체적인 사실관계에 비추어 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일한 것을 의미한다.

(2) 판례의 구체적 경향

- 판례는 사실관계의 동일성 여부를 엄격하게 해석한다. 예를 들어 미성년자 주류 제공과 영업소 면적 변경 미신고는 그 기초가 되는 사실관계가 전혀 다르므로 동일성을 인정하기 어렵다. 반면 법적 근거 규정만을 변경하거나, 사실관계의 세부적인 부분만을 수정하는 경우에는 동일성을 인정하여 추가·변경을 허용하는 경향이 있다.

3. 절차적 한계

- 처분사유의 추가·변경은 원고의 방어권을 침해하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다. 따라서 사실심 변론종결 전까지 이루어져야 하며, 당사자에게 충분한 반박 기회가 주어져야 한다.

IV. 사안의 적용

1. 기본적 사실관계의 동일성 검토

- 행정청 A가 당초 내세운 사유인 미성년자 주류 제공은 영업 행위 상의 의무 위반에 해당하며, 새로 발견한 영업소 면적 변경 미신고는 영업 신고 사항의 변경이라는 형식적 의무 위반에 해당한다. 이 두 사실은 사회적 사실관계의 기초가 완전히 상이하므로 판례의 기준에 따를 때 기본적 사실관계의 동일성이 인정되지 않는다.

2. 추가·변경의 허용 여부 판단

- 사안의 경우 시간적 요건은 갖추었을지라도 객관적 요건인 동일성이 흠결되어 있다. 따라서 행정청 A가 소송에서 영업소 면적 변경 미신고 사유를 추가하거나 변경하여 처분의 정당성을 주장하는 것은 허용되지 않는다. 만약 행정청이 해당 사유를 근거로 처분을 유지하고자 한다면, 현재 진행 중인 소송과 별개로 새로운 처분 절차를 밟아야 한다.

V. 결론

- 대법원 판례에 따르면 처분사유의 추가·변경은 당초 사유와 추가 사유 사이에 기본적 사실관계의 동일성이 인정되는 범위 내에서만 예외적으로 허용된다. 사안의 미성년자 주류 제공과 면적 변경 미신고는 그 동일성이 인정되지 않으므로 행정청 A의 주장은 소송에서 받아들여질 수 없다. 이러한 판례 태도는 행정처분의 상대방인 원고가 소송에서 예측하지 못한 불이익을 당하는 것을 방지하고 재판받을 권리를 실질적으로 보호하기 위한 취지에서 확립된 법리라 할 수 있다.